

数字平台服务贸易治理的法律适用困境与中国因应

谈晓文 徐 昕

内容摘要：现有服务贸易规则在适用于数字平台服务时存在诸多困境。在服务类型的认定、服务提供模式的判断，以及同类服务和提供者认定方面，存在法律适用的模糊性和不匹配性；在非歧视待遇的判断中，存在认定成本和举证责任高、易受利弊平衡干扰以及对技术因素是否构成“固有的竞争劣势”缺乏共识等问题；在例外条款的援引方面，存在对公共道德、个人隐私、国家安全等关键术语的认知分歧。中国作为数字服务贸易大国，应积极在多边层面引领数字服务贸易的规则更新，倡导修订服务贸易分类的依据，将技术因素纳入对“改变了竞争条件”的判断。在例外条款援引问题中，恰当地虑及数字平台服务在技术手段、传输内容等方面或可对他国重要的社会价值产生冲击，在审慎适用的前提下寻求服务贸易自由化与一国主权利益之间的平衡。

关键词：数字服务 数字平台服务 服务分类 非歧视待遇 例外条款

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2025.11.005

一、问题的提出

随着全球数字经济的蓬勃发展，数字服务贸易在赋能企业发展、促进经济增长、缩小数字鸿沟等方面发挥着举足轻重的作用。然而，现有的研究多从经济管理的角度分析数字服务贸易对产业发展的影响(余晓等，2025；于春海等，2025)，忽略了其与传统贸易法的有效衔接。通常意义上的数字服务贸易不仅包含数字化的服务贸易，也包含由数字平台提供的如短视频制作和分发、直播、弹幕评论、数字内容订阅、视频会议等新型服务贸易^①。由数字平台延伸出的数字平台服务贸易范围较为宽广。国家市场监督管理总局在《互联网平台分类分级指

南(征求意见稿)》中将数字平台分为信息资讯类平台(即数字媒体平台)、网络销售类平台(即电子商务平台)、社交娱乐类平台(包含社交网络、即时通信等平台)、生活服务类平台(包括滴滴出行、携程旅行等平台)、金融服务类平台(包括支付结算、证券投资等平台)以及计算应用类平台六种。通过数字平台提供的服务，被称为数字平台服务。此类服务高度依赖平台的实时性、自动化、跨域连接与数据驱动能力，并非简单地将线下服务线上化，而是诞生于数字环境且无法脱离数字平台独立存在的全新服务类型。

对于数字化的服务贸易，基于技术中立原则，仍可以适用 WTO 框架下 GATS 的相关规则，但涉及

[课题信息] 本文是上海市哲学社会科学青年项目“上海对接高标准数字贸易规则推进国际数据港建设研究”(2023EFX006)的阶段性成果。

[作者信息] 谈晓文，上海对外经贸大学世界贸易组织讲席(中国)研究院副研究员；徐昕，上海对外经贸大学国际组织学院(贸易谈判学院)教授。通讯作者：徐昕，电子邮箱：804048116@qq.com。作者感谢匿名审稿专家们的宝贵意见和建议，当然文责自负。

① 国际社会对数字服务贸易尚未有统一的界定。世界贸易组织(WTO)、经济合作与发展组织(OECD)、国际货币基金组织(IMF)和联合国贸易与发展会议(UNCTAD)联合发布的《数字贸易测度手册(第二版)》(Handbook on Measuring Digital Trade, Second Edition)，将“数字贸易”定义为数字化订购(digitally ordered)和/或数字化交付(digitally delivered)的国际贸易。这与现有国际贸易规则项下货物贸易和服务贸易的二分法分属两种不同的分类逻辑。因此，中文语境下的数字服务贸易存在两个维度的上位概念，即数字贸易和服务贸易。由于数字贸易目前并无通行的国际规则，而服务贸易领域则存在 WTO 框架下的《服务贸易总协定》(GATS)，有关服务贸易的概念、分类和市场开放的规则都是比较明确的，因此本文从“服务贸易”这个上位法维度展开论述。即使是 UNCTAD 在提及“数字服务贸易”这一概念时，也是从现有的 12 大类服务贸易中筛选出 6 类(保险和养老金服务，金融服务，知识产权使用费，电信、计算机和信息服务，其他商业服务，以及个人、文化和娱乐服务)并称之为“服务贸易数字化”(digitization of services trade)(UNCTAD, 2022)。

由数字平台延伸出的数字平台服务贸易时,国际通行的规则能否适用仍然存疑。以抖音跨境提供短视频服务为例,部分 WTO 成员颁布特定法律法规或者行政命令,以保护个人隐私、维护本国公共秩序或国家安全等理由,限制抖音向其境内提供此类服务,而其本国或第三国提供的类似服务则不受限制。当越来越多的 WTO 成员采取此类措施时,能否通过多边贸易体制及时提供救济,或是对成员采取此类措施施加必要限制,成为包括中国在内许多新兴经济体迫切需要面对的现实问题。

此时,若中国向 WTO 申诉该法规违反 GATS 项下的非歧视待遇,争议事项将主要聚焦于如下三个方面:其一,数字平台服务贸易在 GATS 服务贸易项下应如何分类,以及其服务提供模式应如何认定。这一认定也将直接关系到如何判断“同类服务和服务提供者”。其二,需评估限制数据跨境流动的措施对数字平台服务贸易造成的限制效果,是否导致外国服务和服务提供者未能享有“不低于的待遇”(treatment no less favourable)。其三,需要判断 GATS 项下一般例外和安全例外条款,是否可以作为限制数据跨境流动的数据措施提供正当性依据。本文围绕以上三个问题展开针对性分析,并在此基础上,针对跨境数字平台服务贸易对传统服务贸易规则的挑战,提出行之有效的中国方案。

二、数字平台服务对服务贸易 概念和性质的挑战

数字平台服务贸易在计算机、通信和网络结合的基础上,跳出了技术手段对服务提供模式的桎梏,展现出高度的互动性、融合性与形式多样性。因此,20 世纪 90 年代议定的服务贸易规则适用于如今的数字平台服务时,在服务类型的认定、服务提供模式的判断,以及同类服务和服务提供者的认定方面难免出现法律适用的模糊性和不匹配性。

(一)对数字平台服务类型的认定

通常而言,根据不同的经济活动领域,可以对服务进行分类,实现差异化管理。例如, WTO 通过 GATS 建立了国际统一的分类框架,将服务分为建筑、金融、教育、旅游等 12 大类(W/120)。联合国统计委员会(United Nations Statistical Commission, UNSC)则制定了《产品总分类》(Central Product Classification, CPC)^①,为全球服务经济数据统计提供了统一采集标准。同时, CPC 分类中“通信服务”“金融服务”等类别与 GATS 项下的 12 类服务目录兼容,确保了统计口径的一致性,也确保了 WTO 与联合国规则体系的协调性。

然而,“数字平台服务”这一概念,在一定程度上模糊了原本较为清晰的服务类型的分界。例如,当短视频服务的服务提供者从 A 国向 B 国提供短视频观看、订阅、弹幕等服务时,可以视为有三种服务同时提供。

第一种是“视听服务”(audiovisual service)。根据字典及通常含义,“视听服务”涵盖与视觉和听觉相关的活动。虽然都属于“视听服务”,但 WTO 各成员在其 GATS 项下具体承诺表中的表述略有差异。中国在具体承诺表中,将视听服务描述为“视频,包括娱乐软件和分销服务(CPC 83202);录音制品分发服务;电影院及剧院服务”。在美国的具体承诺表中,“视听服务”则包含了电影及录影带制作及发行服务(CPC 9611)、电影放映服务(CPC 9612);广播及电视服务(CPC 9613)、广播电视传输业务(CPC 7524)以及录音服务。因此,无论是电视剧、短视频还是电影,在抖音、腾讯视频等网站或者 App 上播放的内容,广义上都属于视听服务的范畴。

第二类是“计算机及相关服务”(computer and related services)。按照 CPC 的分类,“计算机及相关服务”属于第 84 分类,其涵盖大量与数据处理相关的服务类型,包括软件应用服务(CPC 842)、数据处理

^① CPC 是自愿性标准,目前已发布过暂定版、1.0 版、1.1 版、2.0 版和 2.1 版等五个版本。鉴于包括中国、美国在内的成员在商定 GATS 项下的具体承诺表时采用的 1.0 版,本文也相应采用 1.0 版进行论述。

服务(CPC 843)等。当境外的消费者访问我国境内的小红书、腾讯视频等软件,享受短视频、网剧、网络电影等服务时,就意味着其通过计算机软件、手机App等程序,将存储在境内的数据传输到外国服务器或者软件上,从而实现服务的跨境提供,反之亦然。因此,跨境提供短视频、线上购物等服务,可以理解为计算机服务及其项下的数据处理服务。

第三种是电信服务(telecommunication service)。电信服务包括基础电信服务和增值电信服务,其中基础电信服务包括所有形式的语音电话和数据传输,以及租用电路容量服务,增值电信服务主要包括消息传递和在线信息,以及数据检索和处理服务(WTO, [2025])。提供短视频服务通常是指通过互联网或移动通信网络向用户提供内容创作、上传、分发及观看服务。在我国,根据《电信业务分类目录(2015年版)》,此类服务符合第二类增值电信业务项下“信息服务业务”(B25类)的定义,即通过信息采集、开发、处理和平台建设,利用公共通信网络(如互联网、移动网)直接向终端用户提供信息搜索查询、信息即时交互等服务。据此,至少在我国,提供短视频等服务可以被归类为电信服务的范畴。

综上所述,短视频服务可能同时归属于视听服务、计算机及相关服务以及电信服务三种服务类型,形成了服务类型的重叠以及竞合。当W/120没有明确将“数字平台服务”单独分类,而是需要通过解释将其归入既有的服务分类时,就产生了对服务分类的争议,这对WTO成员服务贸易具体承诺表的适用带来挑战。该种挑战进一步体现在服务提供模式的判断上。

(二)对数字平台服务提供模式的判断

GATS主要包括四种服务提供模式,即跨境交付(模式一)、境外消费(模式二)、商业存在(模式三)和自然人流动(模式四)。WTO成员在其GATS项下的具体承诺表中,对四种模式分别作出是否提供国民待遇的承诺。但是,对于数字平台服务而言,即使确定了服务类别,其服务提供的模式仍存在争议,对判定成员是否对该服务提供模式作出了具体承诺带来挑战。

仍以抖音提供的短视频服务为例说明。字节跳动在美国通过投资的方式,设立TikTok(即抖音的国际版)来提供短视频服务。鉴于TikTok依据美国法律登记注册为美国公司,此种服务提供模式属于商业存在。与此同时,美国用户除了可以观看在美国本土制作的短视频外,还可以观看来自英国、俄罗斯等地的视频。由于观看视频需要从外国的网络服务器直接将数据传输到美国境内,如仅考虑数据跨境传输服务,则属于通过跨境交付模式提供服务。再者,由于TikTok受到美国政府限制,大量美国用户主动跨境访问了网络服务器位于中国境内的抖音和小红书,这属于以境外消费模式享受短视频服务。

在GATS项下各成员的具体承诺表中,就容易混淆的视听服务、计算机及相关服务以及电信服务而言,同时对这三种服务提供模式作出承诺的成员不在少数(见表1)。然而,承诺开放的背后,WTO成员都或多或少对市场开放施加了限制性要求。例如,加拿大对通过商业存在模式提供电信服务,要求以设施为基础的电信服务供应商至少80%的董事会成员必须是加拿大人。而且,一家加拿大电信运

表1 WTO成员承诺提供国民待遇的具体情况

服务分类	已通报成员数	对不同服务提供模式作出承诺的成员数			
		模式一	模式二	模式三	模式四
视听服务(CPC 961**)	39	30	34	29	2
计算机及相关服务项下“数据处理服务”(CPC 843**)	67	61	58	60	9
电信服务项下“电子数据交换”(CPC 7523*)	72	66	64	64	11

数据来源:根据WTO和世界银行统计信息摘录。
注:CPC 961**代表“视听服务”包括多个以961开头的五位编码类型,CPC 843**、CPC 7523*同理。

营商有表决权的股份中，外资所有权最高允许比例为46.67%(包括直接持股或是通过控股公司的间接持股)。因此，该电信服务供应商必须由加拿大人控股(WTO Trade in Services, 1997)^①。又如，俄罗斯虽然对视听服务的国民待遇作出承诺，但仅涵盖出售或出租电影或录影带的方式，不包括向公众播放或电子传输等其他形式的传输。再如，欧盟总体上对计算机及相关服务项下“数据处理服务”的国民待遇作出承诺，但马耳他除外(WTO Trade in Services, 2019)。

由于WTO成员对不同的服务提供模式施加了不同的限制，因而明确具体的数字平台服务归属于哪种服务提供模式，就决定了成员在其具体承诺表项下的权利和义务。据此，如果服务提供模式存在争议，那么成员对其具体承诺表的履行也会存在争议，容易引发纠纷。

(三) 对同类服务和提供者认定

如要判定在外国服务和提供者之间，以及外国与本国服务和提供者之间存在歧视性待遇，就需要在同类服务和提供者之间进行比较。对“同类”(likeness)的认定是GATS项下认定违法性的难点，在提供数字平台服务的情况下，难度则进一步加大。

上诉机构在巴拿马诉阿根廷金融服务案(DS453)中，认为“同类”强调相比较的服务和服务提供者之间存在竞争关系，但也提出存在竞争关系并不意味着一定是同类服务和提供者。因此，对“同类”的认定需逐案分析。在该案中，上诉机构将GATT 1994项下对“同类产品”的四类认定标准转化至服务贸易领域，并据此作出同类与否的裁定。然而，GATT 1994标准的转化适用，或许适用于电子支付等在GATS项下有明确分类的服务，但对于无明确分类的数字平台服务而言存在较大的适用困难。

首先，数字平台服务的“性质和特点”难以作出实质性区分。例如，京东和抖音都提供网购服务，前者以综合性线上平台为载体提供网购服务，后者

主要以直播或短视频的方式，通过与用户的线上互动提供网购服务。虽然两者都是网络购物，但从服务的“性质和特点”来看，存在一定区别。在欧盟香蕉III案(DS27)中，专家组指出，可以根据服务所涉产品的来源地是否唯一来判断服务的“性质和特点”是否相同。虽然京东和抖音所涉网购产品的服务来源可能一样(销售企业可能同时在两个平台注册)，但其达成网购的方式存在区别，京东主要是通过平台浏览，抖音主要是通过直播互动。因此，传统上考虑服务“性质和特点”的标准，很难适用于区分数字平台服务。

其次，“产品的终端用途”和“消费者偏好”的转化适用存在困难。以视频服务为例，一方面，视频服务的内容和功能存在重叠。如以功能区分，看球赛和看电视剧就属于同样的视频功能；如以内容区分，看球赛和看电视剧就属于不同类型的服务。此时，如果服务内容和功能相同而提供服务的技术手段不同，如通过视频网站观看和通过有线电视观看电视剧，则又无法完全认定属于同类服务。另一方面，消费者偏好的判断与服务所涉领域的判断存在重叠。例如，在中国电子支付服务案(DS413)中，专家组认为中国银联和其他电子支付服务提供者对经营范围的描述非常相似，这表明两者存在竞争关系。以腾讯视频和爱奇艺为例，即使能够证明两者消费群体不同，但在没有证据证明两者经营范围不同、服务领域不同的情况下，仍然不能说明它们提供不同的服务。

最后，技术因素影响对“存在竞争关系”的判断。数字平台服务的内容多样，包含电子支付、网络购物、外卖、点评、观看视频、视频弹幕、智能搜索等等，而且还在随着技术的发展不断变化。从软件层面来看，这些服务分属不同的服务类型，且提供服务的模式也存在区别。但在技术层面，无论是短视频、网络购物，还是即时通信服务，都是依托数据的收集、处理、跨境等实现的。因此，在

^① 同样，在日本的具体承诺表中，对通过商业存在模式提供电信服务施加了提供国民待遇的限制条件，即该商业存在的董事会成员和审计人员必须具有日本国籍。

GATS 项下具体承诺表中，均体现在计算机及相关服务项下的“数据处理服务”中。那么，回归到对“同类”服务的判断，是否需要追究到技术层面来对同类服务和服务提供者进行认定，还是仅仅停留在软件层面，根据服务的内容、功能、消费者偏好等因素考量竞争关系的存在，仍有待进一步明确。

三、数据措施对“待遇不低于”的挑战

虽然许多 WTO 成员在 GATS 项下对视听服务、计算机及相关服务、电信服务等诸多服务作了承诺，但实践中成员颁布了大量对市场准入、最惠国待遇和国民待遇等进行限制的法律法规和行政命令等来管理和规范数据的收集、存储、流通和传输，属于限制数据跨境流动的数据措施 (Marel et al., 2021)。

影响数字平台服务贸易的数据措施主要分为对内和对外两类。第一类是对国内服务及服务提供者生效的数据措施，主要包括数据分类管理要求、数据出境安全评估措施、数据出境标准合同等。例如，根据我国《数据出境安全评估办法》，重要数据出境、关键信息基础设施运营者收集和产生的个人信息出境，应当进行数据出境安全评估。又如，美国颁布了《保护美国人数据免受外国对手侵害法案》(Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act)，禁止将美国人的敏感数据，如身份识别信息、金融账户号码以及精确地理位置等，向中国、俄罗斯等“受关注国家”传输。第二类是对外国服务及服务提供者生效的措施，主要包括数据本地化措施、“充分性认定”措施等。例如，《俄罗斯联邦个人数据法》第 12 条规定，所有外国公司必须在俄罗斯境内的服务器上存储和处理俄罗斯公民的个人信息。这意味着数据跨境流动必须以本地化存储为前提，只有在符合法定情形时才能进行跨境传输。俄罗斯还建立了“白名单”制度，允许数据在法律规定的范围内跨境流动。又如，欧盟《通用数据保护条例》

(General Data Protection Regulation) 第 45 条规定，只有在第三国提供了“充分保护”时，才能将正在处理或传输后进行处理的数据向第三国进行传输。在这一措施项下，数据从欧盟向第三国或地区流动受到的限制远远大于其在欧盟境内流动时受到的限制 (Fuster, 2016)。

上述影响数据跨境流动的措施^①，不可避免地对数字平台服务贸易产生影响。但是，只有当这些措施在“同类”外国服务和服务提供者之间，或是在“同类”外国与国内服务和服务提供者之间实施差别待遇，即没有提供“不低于的待遇”的情况下，才会构成对 GATS 的违反。因此，除了需明确数字平台服务是否属于 GATS 规范的范围，以及如何认定同类服务和服务提供者以外，还需进一步审视相关数据措施是否对数字平台服务和服务提供者给予了差别待遇。上诉机构在巴拿马诉阿根廷金融服务案中指出，对“待遇不低于”的认定，应当考虑措施的实施“是否改变了竞争条件”，是否对本国的服务和服务提供者更有利 (范德博思等, 2020)。据此，对数据措施是否造成差别待遇至少存在以下三个主要问题：

首先，判断数据措施的实施效果需要较高的成本和举证责任。例如，要评估数据本地化措施的实施效果，即“是否改变了竞争条件”，需要综合考量企业为了遵守数据本地化措施而产生的正负影响，不仅包括建设本地数据中心的租赁和运维成本、带宽费用和合规审批成本等，还需要考量数据本地化对本地云服务商、数据中心的带动效应以及关键数据的安全性。而无论是计算成本，还是评估正向影响，都不能单单以一家企业的情况去判断。考虑到提供数字平台服务企业之间的巨大差异，需要结合较多企业的成本和影响，综合判断数据本地化措施“是否改变了竞争条件”。此外，许多数据措施在形式上都是公平公正的，但外国服务提供者在具体落

^① 部分措施同时涵盖对国民待遇和市场准入进行限制的内容，如美国《1934 年通信法》(Communications Act of 1934) 第 310(b) 条规定了外资持有广播或者通信许可证的限制要求，即美国联邦通信委员会 (Federal Communications Commission) 可基于国家安全或公共利益否决外资收购或控制通信设施的交易 (如电信网络、卫星通信)。

实这些措施时，可能需要付出比本国服务提供者更多的成本，或是面临更多的安全审查。由于“待遇不低于”的解释同时包含了法律上和事实上的歧视，因而此类事实上的歧视或事实上“改变了竞争条件”的认定，也需要根据案件的具体情况“以逐案审查之方式作出”（彭岳，2018）。

其次，对利弊的平衡干扰了对“待遇不低于”的客观判断。在 GATS 项下，“待遇不低于”包含两层判断：第一层考察争议措施是否规定了差别待遇，以及如有规定，该规定是如何作出的；第二层考察差别待遇是否构成较不利的影响。与 GATT 1994 不同，GATS 在判断差别待遇时加入了利弊考量，即考量差别待遇的不利影响。这一不利影响与在判断例外情形时需要考虑的“成员义务与追求国家政策目标的权利之间的平衡”产生一定重合。如何恰当地区分两处平衡考量，赋予差别待遇以客观标准，是判断数据措施是否造成差别待遇的关键。

最后，技术因素是否构成“固有的竞争劣势”仍比较模糊。GATS 第 17(1) 条脚注 10 指出：“根据本条承担的具体承诺不得解释为要求任何成员对由于有关服务或服务提供者的外国特性而产生的任何固有的竞争劣势作出补偿。”以往的 WTO 判例法中，“固有的竞争劣势”往往与语言障碍、文化差异或实际距离相关。但对于数字平台服务而言，即使服务内容相同，采取的技术手段也会存在较大差异。如一 WTO 成员要求提供的数字平台服务要可互操作，那么与本地服务提供者采用相同或类似技术的外国服务提供者则更容易满足可互操作性要求，而采用不同技术的外国服务者就需要付出更多的成本，甚至根本无法满足这一要求。此时，技术因素是否构成“固有的竞争劣势”存在不确定性。

以上诸多不确定性，对判断一项数据措施是否造成“不低于的待遇”带来难度和挑战。其后果是，当一项数据措施影响了数字平台服务贸易时，就很难给予明确认定，有时连成员自身都无法察觉其他成员的措施对其提供数字平台服务造成了不利影响，这进一步加剧了数据措施对 GATS 的挑战。

四、“数据保护”对一般和安全例外的挑战

与 GATT 1994 体例类似，GATS 为 WTO 各成员提供了一般例外和安全例外条款，以此平衡服务贸易自由化与其他社会价值和利益的冲突。GATS 一般例外条款列举了保护公共道德等五种特别需要保护的社会价值和利益。具体到数字平台服务贸易领域，由于数字平台服务往往涉及特定的文化输出，进而对他国文化遗产和历史存续产生冲击，这或可使 WTO 成员有权援引公共道德或公共秩序的例外进行抗辩。此外，在提供数字平台服务的过程中，常涉及个人信息的处理和传播，多数国家对此会有基于个人隐私权方面的立法保护。再者，各国出于防止消费欺诈、便利执法、促进产业发展等政策考量，也会诉诸立法施加限制，这或许使成员有权基于 GATS 第 14 条(c)项中“为执行不与本协定规定相抵触的法律法规”这一理由进行抗辩。自 GATS 生效以来，国家安全例外极少被援引。然而，在当前国家安全泛化的背景下，GATS 第 14 条之二第 1 款(a)项涉及的“如披露则会违背一国基本安全利益的任何信息”或可得到扩张性解释，同时引发网络安全在该条下的适用问题（刁大明，2025）。下文围绕数字平台服务贸易适用这三项例外存在的具体挑战和争议展开讨论。

（一）“公共道德或公共秩序”的抗辩

数字平台服务贸易越来越多地涵盖数字化的文化服务，如游科互动出品的《黑神话·悟空》向全球用户提供网络游戏服务，又如阅文集团向海外用户提供中文翻译作品和当地原创作品。该类服务兼具经济性和文化性两种属性。在其展现的文化性方面，存在是否可援引公共道德或公共秩序例外的争议。

总体来看，对数字平台服务的文化性大体包括两种类型的考量：其一，以联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》（Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions）为代表，倡导文化多样性发展，避免形成一种单一的文化趋势（章建刚，2011）。例如，法

国就在其对外经贸谈判中非常坚持此种考量之下的文化例外^①。其二，基于政治安全和意识形态的角度看待数字平台服务的文化冲击。不同国家在宗教传统、政治制度、社会形态和群体价值观等方面存在差异，导致其更侧重从国家安全的高度看待和评估他国包含文化传播的数字平台服务。不论一国出于以上哪种类型的考量，若其为此目的采取相关限制措施，在现有的 GATS 条款中，仅有公共道德或公共秩序例外可用于此类抗辩。

GATS 第 14 条(a)项提及公共道德和公共秩序两个概念，但都没有明确的界定。其中对“公共秩序”通过脚注施加了限定：“只有在社会的某一根本利益受到真正的和足够严重的威胁时，方可援引公共秩序例外。”在美国赌博案(DS285)中，专家组在正式对公共道德或公共秩序进行解释前，先确立了三项解释原则：其一，公共道德和公共秩序的概念会因成员的不同，而涵盖不同的社会、文化、道德和宗教价值，且会随着时间和空间的变化而变化；其二，在对不同成员适用同一概念时，应赋予成员一定裁量空间，由成员自行决定何种价值观符合自己的公共道德和公共秩序；其三，尽管各成员对公共道德和公共秩序所含社会价值范围的认知存在差异，但依据条约的有效解释原则，专家组仍须就争议条款作出明确解释。

专家组在美国赌博案中，对公共道德或公共秩序的概念宽泛解释具有包容“文化例外”或“文化安全”的张力。但由于“公共”一词的内涵要求某项道德标准或某种秩序隶属于成员境内的社会共同体，而不仅是政府、执政党或某一类群体的选择，因而证明公共道德或公共秩序需满足较高的证明标准。此外，若要成功援引该例外，成员方还需确保相关限制措施并未超过必要限度，即通过“必要性测试”。因此，总体上援引公共道德或公共秩序例外的难度是比较高的。

当前，科技的发展使得文化类数字平台服务得以跨越边境迅猛传播，更多的新兴区域贸易协定与

专项协定注意到了这一问题，并对此加以明确规制。实践中包含两种模式：其一，在相关的协定中明确允许某些特定领域的文化类数字平台服务豁免非歧视义务。例如，美欧在《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP)的磋商中就明确排除了文化和视听服务(European Parliament, 2016)。其二，原则上将文化类数字平台服务排除在服务贸易自由化承诺的范围外，同时在贸易协定中附上文化合作议定书或文化合作条款，如《欧盟—韩国自贸协定》等。

短期之内，GATS 的条款不太可能得到更新，然而作为全球范围内唯一的多边服务贸易协定，GATS 最大限度地调整了不同成员之间的服务贸易，具有无可比拟的优势和价值。为了维持 GATS 的生命力，应该赋予公共道德例外或公共秩序例外更多的解释空间，使其事实上承担“文化例外”的功能。

(二) 遵守相关法律法规的抗辩

面对外国提供的数字平台服务，WTO 成员常会因保护个人隐私、防止消费欺诈、促进产业发展、便利执法等政策关切制定立法，加以限制。但 GATS 本身没有限定成员施加此类限制的权力，而是通过第 14 条(c)项提供某种平衡。按照该项规定，一成员需满足以下条件方可援引其授权的例外：其一，存在与其所列举的内容相关的法律法规；其二，该法律法规不与 GATS 相违背；其三，相关限制措施为执行该法律法规所必需。由于必需性的标准与其他服务贸易领域下的具体适用无异，以下围绕前两个构成要件展开分析。

1. 如何判断存在与所列内容相关的法律法规

该项构成要件具体又分为两个部分：一是“法律法规”的内涵如何辨析，二是“与所列内容相关”的外延如何界定。如前所述，数字平台服务贸易作为新兴产业，相关的规则正处在制定和发展过程中。从立法层级来看，这些规则既包括一国的国内法，也包括一国参加的国际条约或协定；从效力层次来看，既包括具有法律拘束力的硬法，也包括国际机构制定的指南或示范法等软法。根据 WTO 既往案例

^① 法国作为文化例外的坚定支持者，曾在 GATT 初期的谈判中倡导将“文化例外”纳入 GATT 的一般例外条款下，但没有获得支持。

对法律法规的解读，通常应持狭义理解，即不论其原始形态为何，应由成员通过国内立法机构赋予具有拘束力和执行力的规则样态。因此，若一国并未在国内立法上完成吸纳 OECD 有关数据贸易的指南等相关软法的程序，则该国无法仅以遵守指南要求为由援引该项例外。

关于“与所列内容相关”的理解，GATS 第 14 条(c)项所列包含四类：防止欺骗与欺诈行为、处理服务合同违约、保护个人隐私以及保护安全。这里的保护安全是指个人信息安全。实践中，保护个人隐私以及保护安全这两项是大多数数据措施的立法目标。然而，如何理解该项所述个人隐私和安全的涵盖范围，存在较大的解释空间。该项提到了“保护与个人信息处理和传播有关的个人隐私及保护个人记录和账户的机密性”有关的法律法规。从文本解读出发，该项中的“个人隐私”被限定为“与个人信息处理和传播有关”，如果狭义地理解这种措辞，隐私规则的所有内容可能难以被完全涵盖在内，例如，有关数据收集的注册要求就不在范围内(谭观福，2021)。到目前为止，WTO 尚无关于该项所描述的个人隐私例外和信息安全例外的争端解决案例，也没有相关的谈判记录。

2. 如何判断该法律法规不与 GATS 相违背

所谓“不相违背”，有两个层面的解读：一是不违反 GATS 的宗旨和目标，包括序言中所述的推动服务贸易自由化、便利发展中国家扩大服务出口等愿景和期待。那么一国限制数据跨境流动的数据措施是否符合 GATS 推动数字服务贸易自由化的精神呢？这中间存在很大的解释空间和不确定性。二是不违反 GATS 的实体规则。GATS 对影响服务贸易的措施施加了一般义务和具体承诺两大类：前者包括最惠国待遇、透明度，以及国内规制要求等；后者主要包括市场准入和国民待遇。如上文所述，在判断数据措施是否违反“待遇不低于”的问题上存在特别的困难和挑战，不仅影响相关数据措施是否违反非歧视待遇的判断，也影响其是否可援引相关法律法规抗辩的判断。

综上所述，在数字平台服务贸易中，保护个人

隐私方面的数据限制措施是否符合相关法律法规抗辩的构成要件，存在较大的解释空间。为避免该项例外遭到滥用，应在个案裁决的基础上，总体持严格解释的立场。

(三) 国家安全例外的抗辩

GATS 第 14 条之二第 1 款提供了三项国家安全例外，总体上围绕传统的军事、政治领域的国家安全设计。在数字平台服务贸易的情境下，由于数字平台主要围绕泛文化领域提供内容输出，以满足个体各类精神需求为目标，因此就该类服务本身而言，很难与 GATS 第 14 条之二第 1 款后两项国家安全例外挂钩。但在经济秩序变革时期，部分国家利用安全例外条款的模糊表述，将其作为实现法律利己目的的工具(马忠法等，2024)。因此，第 14 条之二第 1 款(a)项涉及的“如披露则会违背一国基本安全利益的任何信息”或将得到扩张性解释。例如，实践中，很多国家采取限制数字平台服务提供的网络安全措施，如对其中涉及的数据跨境流动进行严格的安全评估，要求企业采取强制性的国内标准以及数据本地化措施等。采取网络安全措施的国家通常主张国家安全例外条款使其措施正当化，此种情况下国家安全例外的抗辩或可被援引。

然而，那些基于维护国家安全的理由限制数据跨境流动的国家，并未就这些限制措施在实践中如何回应国家安全关切提供明确的论据。强制公司在本地存储或处理数据既不能确保网络在受到攻击时仍能正常运行，也不能确保通信系统在受到攻击时更容易复原。无论数据存储在何处，薄弱的安全系统仍然是薄弱的(Ferracane, 2019)。此外，如果数据集中存储于某个明确的位置，则其受到网络攻击的可能性更高。因此，限制数据跨境流动的措施与基本安全利益之间的合理联系难以满足。

综上所述，对于限制数字平台服务贸易的措施，国家安全例外条款理论上极难获得援引。事实上，虽然时代进步和技术发展推动各方不断更新对传统国家安全的理解，但安全例外作为最后的安全阀(Bacchus, 2022)，始终应在严苛的条件下得以适用，成员对此亦应秉承善意和克制原则，并应在

WTO 框架下对安全例外条款予以进一步澄清和规范 (卢琦等, 2024)。

五、数字平台服务贸易与现有规则衔接的对策建议

数字平台服务贸易是时代发展的产物, 其在总体贸易产值和效益中的比重也在不断加大。WTO 对数字平台服务贸易的规制需要尽早筹谋, 为成员数字平台服务贸易活动提供适合的法律框架, 减少不必要的纠纷。考虑到数字平台服务对传统服务贸易规则的诸多挑战, 我国应当在多边场合更积极地发挥作用, 引领数字平台服务贸易相关议题。

(一) 对准规则衔接的主要难点, 提出规则改革的中国方案

首先, 要明确数字平台服务贸易的分类。关于数字平台服务贸易的分类, 总体而言, 存在三种重构分类的路径。第一, 在不改变现有服务贸易分类逻辑的情况下, 以服务部门的数字化转型为基础, 将数字相关的服务贸易分为数字金融服务、数字电子商务、智能物流和运输、数字化医疗和健康服务、智能旅游和文化创意, 以及数字化教育和培训等数字化的服务部门 (黄建忠等, 2024)。第二, 适当将技术因素纳入考量, 或是根据算法的功能, 如推送、筛选、排序及合成等, 对数字平台服务贸易进行分类 (许可, 2022)。第三, 参照《数字贸易测度手册 (第二版)》, 将数字平台服务贸易纳入数字订购服务和数字交付服务的分类, 并整体纳入服务贸易规则。这一分类主要是出于数据统计便利的考量, 因为相关统计数据大多来源于基于数字交易而产生的订购和交付两类数据。因此, 以数字订购和交付服务为基础重构服务贸易规则, 不失为一条可行之路。

其次, 要厘清数字平台服务的提供模式。关于数字平台服务的提供, 面临是否有必要区分四类服务提供模式的问题。如果对数字平台服务贸易分类的判定仍然遵循传统的经济部门分类方法, 则有必要保留四种服务提供模式; 如果按照技术因素认定数

字平台服务贸易的类型, 那么就需要重新认定数字平台服务的提供模式。综上所述, 数字平台服务分类、服务提供模式的认定、同类服务和提供者认定三者环环相扣, 对其中一项的改变势必会对其他两项产生影响, 所以需要从整体角度充分考量。

最后, 要确立非歧视性待遇的修正标准。在判断一项数据跨境流动措施是否“改变了竞争条件”并对服务贸易构成限制时, 必须坚持“以逐案审查方式作出”。要适当简化在这一步中的利弊平衡, 以与例外条款中的利益平衡作区别。简化的目的是查明该措施是否对同类数字平台服务及服务提供者造成不利影响。此处应当对不利影响作简单理解, 在此基础上, 再考虑技术因素是否构成固有的竞争优势。即使不单独将技术因素认定为固有的竞争优势, 也可尝试将其作为判断依据之一。

(二) 规范对例外条款的援引, 平衡好国家主权与贸易自由

规范对例外条款的援引, 核心是坚持不能滥用例外抗辩。无论是一般例外中的公共道德或公共秩序的抗辩, 还是遵守相关法律法规的抗辩, 都必须建立在对比例原则严格适用的基础上。主要从以下三方面进行判断: 一是该措施是否以保护公共道德或公共秩序, 或是遵守相关法律法规为目的 (目的性); 二是该措施是否有助于保护公共道德或公共秩序, 或是有助于遵守相关法律法规 (适当性); 三是在多个能够达成目的的措施中, 该措施的损害后果和影响效果是否为最小 (必要性)。因此, 要在引入“必要性”测试的基础上, 严格适用比例原则^①。

而对于国家安全例外的抗辩, 一方面, 要坚持援引该条款应秉持善意和克制原则, 对“基本安全利益”作合理的主观判断。要严格界定“基本安全利益”等核心概念, 将这一概念限缩于国家军事安全、领土完整、公共秩序等核心领域, 排除一般性经济或产业保护目标, 而且要明确例外条款的适用场景, 避免泛化解释 (鄂晓梅, 2024)。另一方面, 要推动

^① WTO 案例中有关一般例外适用的“比例原则”是指, 成员方在援引一般例外条款 (如 GATT 1994 第 20 条或 GATS 第 14 条) 时, 需通过“适当性”“必要性”“狭义比例性”三方面检验, 以平衡贸易限制措施与所追求的合法目标 (如公共道德、环境保护等) 之间的关系。

对国家安全例外抗辩在 WTO 框架内的进一步规范。可借鉴《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)的“合作性合规审查”模式,设立缔约国联合委员会,定期评估例外措施的实施效果,防止保护主义倾向。除传统例外条款外,还可探索“安全合作条款”,如建立跨境数据流动安全认证、特定领域联合信息共享等机制,通过合作降低采取单边例外措施的必要性。

(三)持续深化制度型开放,提升我国国际规则话语权

首先,要持续扩大包括数字平台服务贸易在内的服务贸易开放,在明确数字平台服务贸易分类、厘清服务提供模式的基础上,完善全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单。聚焦专业领域,重点考虑在电信、医疗、教育等领域放宽数字平台服务的准入限制。在放宽限制的同时,也要考虑数字平台服务提供的新情况、新特点和新问题。针对当前存在的监管空白和国际协调真空问题,需在双边、区域以及 WTO 框架下加强协调。

其次,要进一步开放我国数字市场,降低数字平台服务贸易壁垒水平。欧洲国际政治经济中心(European Centre for International Political Economy, ECIPE)发布的《数字贸易限制指数》(Digital Services Trade Restrictiveness Index)显示,中国跨境数字贸易限制较多,在互联网接入、电子商务、支付系统、知识产权等领域,跨境数字贸易壁垒远远高于世界平均水平。要推动数字平台服务贸易的制度型开放,就必须放宽数字领域的市场准入,提高数字贸易领域外资企业在境内投资运营的便利化水平。

最后,要扩大数字贸易领域对外合作,对接国际高标准经贸规则。近年来,我国积极参与 WTO、亚太经济合作组织(APEC)等多双边和区域数字贸易相关规则制定,积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和 DEPA 进程,也持续加强与东盟、中亚和金砖国家等数字贸易合作。下一步,要进一步围绕数据跨境流动、数字知识产权保护等领域加强合作,尝试建立数字贸易国际联合实验室,谋划共建《全球跨境数据流动合作倡议》的具体路径,探索与其他国家共建数字贸易伙伴关系网络。

立足新发展阶段,创新发展数字平台服务贸易,推动数字平台服务贸易制度化、法治化和规范化发展,对建设现代化经济体系具有重大意义。今后一个时期,我国一方面要加快打造数字贸易发展新优势,另一方面,要重视数字平台服务贸易对传统贸易规则的挑战,主动提出规则的更新方案,为推动构建开放型数字经济和全球经贸治理提供合作基础。

参考文献

- [1] 刁大明. 从 1.0 到 2.0: 特朗普政府对华安全战略的延续与政策变化[J]. 国际安全研究, 2025, 43(1): 96-114.
- [2] 鄂晓梅. WTO 安全例外条款解释与适用研究——以中美半导体措施案为例[J]. 国际法研究, 2024(6): 74-91.
- [3] 范德博思, 单文华. 世界贸易组织法原理(上册)[M]. 尚宽, 贺艳, 译. 北京: 法律出版社, 2020: 368.
- [4] 黄建忠, 蒙英华, 赵玲. 服务业数字化转型与服务贸易高质量发展——以上海为例[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(4): 144-154.
- [5] 卢琦, 王盈颖. 数智时代安全例外条款的适用边界探析——兼对 TikTok 剥离法作法律分析[J]. 国际贸易, 2024(10): 58-66.
- [6] 马忠法, 徐子淳. 论 WTO 安全例外条款的解释路径及其对中国的启示[J]. 国际商务研究, 2024, 45(6): 38-51.
- [7] 彭岳. 数据本地化措施的贸易规制问题研究[J]. 环球法律评论, 2018, 40(2): 178-192.
- [8] 谭观福. 数字贸易规制的免责例外[J]. 河北法学, 2021, 39(6): 102-120.
- [9] 许可. 算法规制体系的中国建构与理论反思[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2022, 40(1): 124-132.
- [10] 于春海, 许茜, 孙浦阳, 等. 数字服务贸易的竞争与进口替代效应分析——基于数字贸易企业的微观证据[J]. 国际金融研究, 2025(4): 85-96.
- [11] 余晓, 戴阳锋, 陈迁, 等. 数字治理分歧、制度距离与数字服务出口——来自亚太经济体的证据[J]. 国际贸易问题, 2025(4): 56-73.
- [12] 章建刚. 教科文组织的文化多样性立场[J]. 江汉大学学报(人文科学版), 2011, 30(1): 25-30.
- [13] BACCHUS J. The black hole of national security: Striking the right balance for the national security exception in international trade[R/OL]. (2022-11-09) [2025-05-20]. <https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2022-11/policy-analysis-936.pdf>.

- [14] European Parliament. European Parliament resolution of 23 May 2013 on EU trade and investment negotiations with the United States of America (2013/2558 (RSP)) [A/OL]. (2016-02-12) [2025-05-22]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013IP0227>.
- [15] FERRACANE M F. Data flows and national security: a conceptual framework to assess restrictions on data flows under GATS security exception[J]. Digital policy, regulation and governance, 2019, 21(1): 44-70.
- [16] FUSTER G G. Un-mapping personal data transfers[J]. European data protection law review, 2016, 2(2): 160-168.
- [17] MAREL E V D, FERRACANE M F. Do data policy restrictions inhibit trade in services? [J]. Review of world economics, 2021, 157(4): 727-776.
- [18] UNCTAD. Digitalization of services: What does it imply to trade and development? [R/OL]. (2022-03-25) [2025-05-25]. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd2021d2_en.pdf.
- [19] WTO. Coverage of basic telecommunications and value-added services [EB/OL]. [2025-05-25]. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_coverage_e.htm#basic.
- [20] WTO Trade in Services. Canada schedule of specific commitments supplement 3: GATS/SC/16/Suppl.3 [A/OL]. (1997-04-11) [2025-05-21]. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/SCHD/GATS-SC/SC16S3.pdf&Open=True>.
- [21] WTO Trade in Services. European Union schedule of specific commitments: GATS/SC/157 [A/OL]. (2019-05-07) [2025-05-22]. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/SCHD/GATS-SC/SC157.pdf&Open=True>.

Legal Application Dilemma of Governance of Digital Platform Services Trade and China's Response

TAN Xiaowen XU Xin

(Shanghai University of International Business and Economics)

Abstract: There are many difficulties in applying the existing rules of services trade to digital platform services trade. Specifically, there are legal ambiguities and mismatches in the determination of service types, the classification of service modes, as well as in the identification of similar services and service providers. With regard to the assessment of non-discriminatory treatment, challenges persist, such as high identification costs and burdens of proof, susceptibility to interference from the balance of advantages and disadvantages, and a lack of consensus on whether technological factors constitute an “inherent competitive disadvantage.” In the invocation of exception clauses, there are cognitive differences regarding key terms such as public morality, personal privacy, and national security. As a major player in the digital services trade, China should actively lead the update of rules for digital services trade at the multilateral level, advocate for a revised framework for classifying services trade, and incorporate technological factors into the assessment of “modified conditions of competition.” In the invocation of exception clauses, it is necessary to appropriately consider that digital platform services may have an impact on important social values of other countries through technical means and transmitted content, and seek a balance between services trade liberalization and the sovereignty interests of a country under the premise of prudent application.

Keywords: digital services; digital platform services; service classification; non-discriminatory treatment; exception clauses

JEL Classification: K33, L18, L86

(责任编辑:王勇娟)